

Les actes administratifs : l'expression unilatérale et contractuelle de la puissance publique au Sénégal

Introduction générale

L'acte administratif constitue le moyen juridique privilégié par lequel l'administration sénégalaise met en œuvre ses prérogatives de puissance publique pour accomplir ses missions d'intérêt général. Il se définit comme une manifestation de volonté émanant d'une autorité administrative ou d'une personne privée investie d'une mission de service public, destinée à produire des effets de droit. Le droit administratif sénégalais, fidèle à sa double tradition textuelle et jurisprudentielle, opère une distinction fondamentale entre l'acte administratif unilatéral (AAU) et le contrat administratif. L'acte unilatéral s'impose aux administrés sans leur consentement, illustrant le privilège du préalable, tandis que le contrat administratif repose sur un accord de volontés, bien qu'il demeure profondément asymétrique en faveur de la personne publique en raison des clauses exorbitantes du droit commun qu'il renferme.

L'évolution historique du régime des actes administratifs au Sénégal est intimement liée à la consolidation de l'État de droit et à la modernisation de l'appareil étatique. Au lendemain de l'indépendance, la loi n° 64-16 du 22 avril 1964 relative au domaine de l'État a posé les premiers jalons d'un droit administratif écrit et souverain, formalisant les prérogatives unilatérales de l'administration sur son patrimoine. Le véritable tournant contemporain s'est opéré avec l'adoption de la loi n° 2011-04 du 30 mars 2011 portant Code de transparence des finances publiques et, plus récemment, avec la loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé et le Code des marchés publics de 2014 (révisé en 2022). Ces réformes majeures témoignent d'une transition d'une administration purement autoritaire vers une administration de plus en plus contractuelle, transparente et soumise aux impératifs de la bonne gouvernance financière et de l'efficacité managériale.

Sur le plan doctrinal, l'étude des actes administratifs cristallise les débats autour de la frontière entre la légalité républicaine et l'efficacité de l'action publique. La doctrine sénégalaise s'est longuement penchée sur la notion d'acte de gouvernement—cette catégorie d'actes insusceptibles de tout recours juridictionnel en raison de leur nature politique ou diplomatique—qui restreint le périmètre du contrôle du juge. De plus, la diversification des autorités émettrices d'actes (agences d'exécution, autorités de régulation) a complexifié la pyramide des normes, soulevant d'intenses controverses sur la hiérarchie et l'opposabilité des décisions administratives. Face à ces tensions, la Chambre administrative de la Cour suprême s'affirme comme le gardien du bloc de légalité, veillant à ce que ni l'urgence, ni les théories des circonstances exceptionnelles ne transforment le pouvoir discrétionnaire de l'administration en un pouvoir arbitraire.

L'analyse des actes administratifs requiert une grille de lecture complète, englobant les conditions de leur validité, les mécanismes de leur exécution, ainsi que les voies de droit permettant d'obtenir leur annulation ou leur modification. Dès lors, comment le droit positif sénégalais parvient-il à encadrer la création et l'exécution des actes administratifs pour garantir l'efficacité de l'action publique tout en protégeant les droits des administrés contre les dérives unilatérales ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps la typologie et les conditions de légalité de l'acte administratif unilatéral. Puis, nous analyserons l'essor et le

régime juridique des contrats administratifs. Enfin, nous étudierons le contentieux de l'annulation et de l'urgence devant le juge administratif sénégalais.

Partie I : La typologie et les conditions de légalité de l'acte administratif unilatéral (AAU)

A. La classification des AAU et les critères d'identification : des décrets présidentiels aux actes des personnes privées

L'acte administratif unilatéral se décline sous plusieurs formes en fonction de l'autorité qui l'édicte et de sa portée juridique. Le droit positif sénégalais distingue en premier lieu les actes réglementaires des actes individuels. L'acte réglementaire pose une règle générale, impersonnelle et abstraite qui s'adresse à un ensemble indéterminé de personnes (par exemple, un décret présidentiel portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti). À l'inverse, l'acte individuel désigne une ou plusieurs personnes nommément identifiées (par exemple, un arrêté ministériel portant nomination d'un directeur d'école ou une décision de révocation d'un fonctionnaire).

La hiérarchie des AAU suit scrupuleusement l'ordonnancement institutionnel de l'État :

- Le décret : acte suprême de l'exécutif, émanant exclusivement du Président de la République (décrets simples ou décrets en Conseil des ministres).
- L'arrêté : acte pris par les ministres (arrêté ministériel ou interministériel), les gouverneurs, les préfets ou les maires dans le cadre de leurs compétences respectives.
- La décision et la circulaire : la décision tranche une situation concrète, tandis que la circulaire (ou instruction) est un acte interne par lequel un chef de service oriente l'action de ses subordonnés. La jurisprudence sénégalaise considère qu'une circulaire n'est susceptible de recours que si elle présente un caractère impératif et ajoute de nouvelles règles au droit positif.

L'identification de l'AAU repose principalement sur un critère organique (l'acte émane d'une personne publique). Cependant, la jurisprudence a consacré une extension matérielle remarquable : les actes pris par des personnes privées peuvent recevoir la qualification d'actes administratifs si cette personne privée est chargée de la gestion d'un service public administratif et qu'elle met en œuvre, pour l'édiction de cet acte, des prérogatives de puissance publique (par exemple, les décisions d'exclusion prises par les fédérations sportives ou les ordres professionnels).

B. Le bloc de légalité et les vices affectant la validité de l'acte unilatéral

Pour être juridiquement valable et s'imposer dans l'ordonnancement juridique, l'acte administratif unilatéral doit respecter l'ensemble des normes supérieures qui lui préexistent, un ensemble qualifié de "bloc de légalité" (comprenant la Constitution, les traités internationaux réformés, les lois et les Principes Généraux du Droit). Tout manquement à ces normes entache l'acte d'une illégalité que le juge administratif sanctionne à travers quatre grands vices classiques.

Le premier est le vice de compétence, qui est d'ordre public et peut être soulevé à tout moment par le juge. Il se produit lorsqu'une autorité prend un acte sans en avoir le droit, que ce soit une incompétence matérielle (empiètement sur le domaine de la loi ou d'un autre ministère), temporelle (acte pris avant l'entrée en fonction ou après la cessation des pouvoirs) ou territoriale (arrêté d'un préfet s'appliquant en dehors de son département). Le deuxième est le vice de forme et de procédure, qui sanctionne le non-respect des formalités substantielles prescrites par les

textes, telles que l'absence de motivation obligatoire de l'acte (exigée par la loi pour les décisions individuelles défavorables) ou le défaut de consultation préalable d'un organisme paritaire.

Le troisième est le vice de violation de la loi, qui touche au contenu même de l'acte : l'administration a fait une fausse application des textes, s'est trompée sur les faits qui justifiaient l'acte (erreur de fait) ou a mal qualifié juridiquement la situation (erreur de qualification juridique des faits). Enfin, le détournement de pouvoir est caractérisé lorsque l'autorité administrative utilise ses compétences dans un but autre que celui pour lequel elles lui ont été conférées, soit pour satisfaire un intérêt purement privé ou politique, soit pour poursuivre un intérêt public mais étranger à celui que la loi visait (par exemple, utiliser des pouvoirs de police des alignements dans le seul but d'éviter à la commune le paiement d'une indemnité d'expropriation).

Partie II : L'essor et le régime juridique des contrats administratifs

A. Les critères d'identification du contrat administratif : la loi face à la clause exorbitante

À la différence de l'acte unilatéral, le contrat administratif naît d'un accord de volontés entre l'administration et un cocontractant. Un contrat peut recevoir la qualification d'administratif soit par la volonté expresse du législateur (qualification législative), soit par l'application de critères jurisprudentiels cumulatifs dégagés par le juge de l'excès de pouvoir et du plein contentieux.

Les qualifications textuelles se sont multipliées au Sénégal pour sécuriser les investissements. En vertu du Code des marchés publics et de la loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé (PPP), tous les contrats passés en application de ces textes sont par nature des contrats administratifs. En l'absence de texte, le juge applique deux critères :

- **Le critère organique** : le contrat doit comporter au moins une personne morale de droit public (l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public). Un contrat passé entre deux personnes privées est par principe un contrat de droit privé, sauf si l'une d'elles agit comme mandataire transparent d'une personne publique.
- **Le critère matériel (alternatif)** : le contrat doit soit avoir pour objet l'exécution même d'une mission de service public, soit comporter des clauses exorbitantes du droit commun. La clause exorbitante se définit comme une stipulation qui confère aux parties des droits ou leur impose des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont librement consentis dans le cadre des lois civiles ou commerciales (par exemple, le pouvoir de résiliation unilatérale sans faute au profit de l'administration ou le contrôle direct de la comptabilité du partenaire privé).

B. L'exécution du contrat et les théories de l'équilibre financier : fait du prince et imprévision

L'exécution des contrats administratifs déroge profondément au principe civiliste de l'égalité des parties contractantes. L'administration dispose de prérogatives exorbitantes durant toute la vie du contrat pour veiller à la bonne marche du service public. Elle possède un pouvoir de direction et de contrôle qui lui permet d'inspecter les chantiers ou d'exiger des rapports, un pouvoir de modification unilatérale pour adapter les prestations aux besoins nouveaux de l'intérêt général, et un pouvoir de sanction lui permettant d'infliger des pénalités de retard, de mettre le contrat en régie ou de prononcer la déchéance du cocontractant en cas de faute lourde.

Pour compenser cette fragilité juridique du partenaire privé et garantir la continuité du service public, la jurisprudence administrative sénégalaise met en œuvre des mécanismes de protection financière rigoureux, regroupés sous les théories de l'équilibre financier du contrat :

- **Le Fait du Prince** : cette théorie s'applique lorsque l'autorité publique contractante prend une mesure légale mais imprévisible qui a pour effet direct de rendre plus onéreuse l'exécution du contrat pour son partenaire (par exemple, une modification de la fiscalité locale spécifique au secteur du contrat). L'administration est alors tenue d'indemniser intégralement le cocontractant pour le préjudice subi.
- **La théorie de l'Imprévision** : formalisée par l'arrêt *Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux* (1916), elle intervient lorsqu'un événement extérieur aux parties, totalement imprévisible et irrésistible, bouleverse temporairement l'économie générale du contrat (guerre, crise économique mondiale, épidémie majeure). Le cocontractant doit continuer à exécuter le service public, mais l'administration est obligée de prendre à sa charge une part substantielle (généralement 90%) des pertes financières subies à travers le versement d'une indemnité d'imprévision, jusqu'au retour à des conditions normales d'exploitation.

Partie III : Le régime d'action de l'acte et le contentieux devant le juge administratif sénégalais

A. L'entrée en vigueur, le privilège du préalable et les règles du retrait des actes administratifs

L'acte administratif unilatéral bénéficie d'une présomption de légalité et produit des effets de droit dès son entrée en vigueur. Pour les actes réglementaires, cette entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au *Journal officiel* de la République du Sénégal ou par voie d'affichage, assurant ainsi l'information des citoyens. Pour les actes individuels, l'entrée en vigueur est conditionnée par leur notification officielle à la personne concernée. L'administration dispose du privilège du préalable, qui l'autorise à édicter des obligations immédiatement exécutoires sans avoir à demander l'autorisation préalable d'un juge. Si un administré refuse d'obéir, l'administration peut, sous certaines conditions strictes (urgence, absence d'autre voie légale), recourir à l'exécution forcée en faisant intervenir la force publique.

L'administration peut également décider de faire disparaître ses propres actes, une procédure encadrée par des règles de sécurité juridique strictes pour protéger les droits acquis des administrés. Il convient de distinguer l'abrogation (qui fait disparaître l'acte pour l'avenir) du retrait (qui anéantit l'acte de manière rétroactive, comme s'il n'avait jamais existé).

Un acte réglementaire ou un acte individuel non créateur de droits (comme un refus d'autorisation) peut être abrogé ou retiré à tout moment si l'administration le juge opportun. En revanche, si l'acte a créé des droits au profit d'un administré (par exemple, un décret de nomination dans la fonction publique ou un permis de construire), l'administration ne peut le retirer ou l'abroger que si l'acte était entaché d'une illégalité originelle, et ce, dans un délai impératif de quatre mois à compter de sa signature. Passé ce délai, l'acte devient intangible, même s'il est illégal, afin de garantir la stabilité des situations juridiques individuelles, forçant l'administration à assumer les conséquences de ses propres erreurs.

B. Les voies de recours juridictionnels : le recours en annulation et l'essor des procédures d'urgence

Le contrôle de la légalité des actes administratifs relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour suprême, régie par la loi organique n° 2017-09 sur la Cour suprême. La principale voie de droit offerte aux citoyens est le recours pour excès de pouvoir (REP). C'est un recours objectif, dirigé contre l'acte lui-même, visant à faire prononcer son annulation rétroactive pour cause d'illégalité. Pour être recevable, le requérant doit justifier d'un intérêt à agir (un intérêt personnel, direct et légitime lésé par l'acte) et introduire son recours dans un délai de deux mois à

compter de la publication ou de la notification de l'acte, après avoir, le cas échéant, introduit un recours gracieux ou hiérarchique préalable auprès de l'autorité administrative.

Parce que le recours pour excès de pouvoir n'a pas d'effet suspensif—l'acte contesté continuant à s'appliquer tant que le juge ne l'a pas annulé—le législateur sénégalais a modernisé les procédures d'urgence pour éviter que l'exécution d'un acte illégal ne cause des dommages irréparables avant le jugement au fond. Le requérant peut ainsi introduire une requête en référé-suspension parallèlement à son recours au fond. Le juge des référés peut ordonner la suspension provisoire de l'acte si deux conditions cumulatives sont remplies : l'existence d'une urgence caractérisée et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.

De plus, le dispositif du référé-liberté permet de saisir le juge en urgence absolue (décision sous 48 heures) lorsqu'un acte administratif porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (comme la liberté de réunion ou la liberté d'aller et venir). Ces mécanismes d'urgence ont considérablement renforcé l'effectivité du contrôle juridictionnel au Sénégal, transformant le juge d'un censeur a posteriori en un arbitre en temps réel des dérives unilatérales de la puissance publique.

Conclusion générale

L'acte administratif, qu'il se manifeste sous la forme impérative de l'unilatéralité ou sous les contours négociés du contrat, demeure l'instrument indispensable du dynamisme étatique sénégalais. Les réformes textuelles successives et l'affinement de la jurisprudence de la Cour suprême démontrent une volonté constante de soumettre la puissance administrative à la discipline du droit. Le privilège du préalable et les théories de l'équilibre financier contractuel confèrent à l'État les moyens d'assurer la continuité des services et le maintien de l'ordre, tout en offrant aux administrés des garanties d'indemnisation et de sécurité juridique.

Cependant, l'analyse contemporaine révèle des zones de friction qui appellent à une vigilance continue. La prolifération d'actes d'exécution non conventionnels, portés par la gestion des agences et la numérisation des procédures administratives, bouscule les catégories classiques de l'AAU et complique l'accès à l'information des requérants. Par ailleurs, la question des délais de jugement devant la Chambre administrative, malgré l'efficacité des procédures de référé, pèse encore sur l'effectivité de la protection des citoyens face à une machine bureaucratique parfois tentée par le passage en force.

L'adaptation future du régime des actes administratifs reposera sur une harmonisation accrue entre les impératifs du nouveau management public, axé sur la performance, et les exigences constitutionnelles de transparence et d'égalité. En garantissant une motivation systématique des décisions et en ouvrant plus largement les procédures de passation des contrats aux PME locales, le Sénégal confortera la légitimité de ses actes publics, transformant la contrainte administrative en un vecteur partagé de progrès économique et de paix sociale.